

- 1 から 5 までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを 2 個選びなさい。
1. 甲は、乙が A 及び B を木刀で順次殴打して両名を負傷させる犯行に及んだ際、これに先立ち、乙の意図を知りながら、凶器として同木刀を乙に手渡し、これらの犯行を幫助した。この場合、甲に 2 個の傷害罪の幫助犯が成立し、これらは観念的競合となる。
 2. 甲は、A を監禁することを目的として、A の手足をロープで縛り付けて逮捕し、これに引き続き自宅に A を監禁した。この場合、甲に逮捕罪及び監禁罪が成立し、これらは牽連犯となる。
 3. 甲は、自宅で A を殺害し、その死体を自宅の庭に埋めて遺棄した。この場合、甲に殺人罪及び死体遺棄罪が成立し、これらは牽連犯となる。
 4. 甲は、火災保険金をだまし取ろうと考え、同居していた妻が不在の間に、自宅に放火して全焼させ、その後に火災原因を偽って火災保険金の支払を受けた。この場合、甲に現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
 5. 甲は、A 名義で預金口座を開設する目的で、A に成り済まして A 名義で口座開設申込書を作成し、これを銀行の係員に提出して、A 名義の預金通帳の交付を受けた。この場合、甲に有印私文書偽造罪、同行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。

No203

共通R 7-B

観念的競合と牽連犯

正解

1、5（順不同）

正答率

80%

1 正しい

最決昭57.2.17（百選I 107事件）は、本記述と類似の事案において、「成立すべき幫助罪の個数については、正犯の罪のそれに従って決定される」としている。その理由として、判例は、「幫助罪は正犯の犯行を幫助することによって成立するものである」ということを挙げている。そして、同判例は、幫助罪が数個成立する場合に、観念的競合の関係となるか否かについては、「幫助行為それ自体についてこれを見るべきである」としている。その理由として、判例は、「幫助犯における行為は幫助犯のした幫助行為そのものにほかならない」ということを挙げている。本記述で、正犯である乙にはA及びBそれぞれに対する2つの傷害罪（204条）が成立するため、乙を幫助した甲には傷害罪の幫助犯が2個成立することになる。そして、甲の幫助行為は、木刀を一本手渡したという1個の行為であるから、甲に成立する2つの傷害罪の幫助犯は、観念的競合の関係になる。

2 誤っている

最大判昭28.6.17は、同一の被害者を逮捕し引き続き監禁したときは包括的に1個の逮捕監禁罪（220条）が成立するとしている。

3 誤っている

大判明44.7.6は、殺人罪と死体遺棄罪とは併合罪（45条前段）になるとしている。その理由として、判例は、死体遺棄行為は常に必ず殺人行為を伴うものではなく、人を殺した後に死体を遺棄する行為は別罪を構成するということを挙げている。

4 誤っている

大判昭5.12.12は、本記述と同様の事案において、放火罪と詐欺罪は併合罪になるとしている。したがって、甲には現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは併合罪（45条前段）となる。

5 正しい

大判明42.7.27、大判明42.1.22。判例は、本記述と同様の事案において、詐欺罪、有印私文書偽造罪及び同行使罪が成立する場合は牽連犯（54条1項後段）になるとしている。

以上により、正しい記述は1と5であり、したがって、正解は肢1と肢5（順不同）となる。